

1500203-68.2019.8.26.0341

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... já tinha sido preso anteriormente por tráfico de entorpecentes. Também foi apreendido pelo tráfico quando era adolescente. Inclusive, quando ele foi ouvido quanto aos fatos, encontrava-se preso em Assis, pela prática de tráfico de entorpecentes. Confirmou que era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500203-68.2019.8.26.0341 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-68.2019.8.26.0341

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, 2185738/2019 - 3716090 -

DEL.POL.MARACAI, 264/19/112

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CAIO HENRIQUE DO BONFIM GARCIA

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Caio Henrique Do Bonfim Garcia foi denunciado como incurso nas sanções do artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, tinha em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 05 porções de cocaína, com peso aproximado de 2,53g, 01 porção de maconha, com peso aproximado de 5,47g e 32 porções de crack, com peso aproximado de 56,52g, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/07 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 38/40, sendo certo que tais substâncias causam dependência física e psíquica.

O denunciado foi notificado (fl. 103) e apresentou defesa preliminar (fls. 115/119).

A denúncia foi recebida em 02/10/2020 - fls. 147/148.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o acusado (fls. 178/179 e 198/200).

Encerrada a instrução o Ministério Público, em Memoriais, requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia (fls. 206/209).

A defesa, em Memoriais, requereu a absolvição, alegando, em síntese, a ausência de provas para a condenação (fls. 213/216).

Relatei. Decido.

De saída, em que pese o teor da petição de fls. 165/166, consoante auto de busca domiciliar de fl. 16, constante no incidente em apenso, autos sob ° 1500148-20.2019, verifico que houve a observância § 4º do art. 245 do CPP, pois assinado por duas testemunhas, que concordaram com os termos do auto de busca domiciliar. Sobre o documento, grava/milita, a presunção legal de veracidade e legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, nos termos da exegese do artigo 37, da Constituição Federal, tendo especial importância, como salientado pelo douto Desembargador Lauro Mens de Mello, no julgamento da Apelação 0006236-27.2015.8.26.0168 (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 27/02/2018) o qual, em excerto, respeitosamente, abaixo reproduzo e me reporto como razão de decidir:

"(...) Desta forma os funcionários públicos, gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALA TESTA ao afirmar que "não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que, além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário público". Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396".(...)Por tais motivos o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.(...)Mais uma vez nada existe no sentido de afastar a validade do depoimento de agente público.Concluindo-se, plenamente válido o depoimento de agente público para embasar decreto condenatório quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.(...)"

Além disso, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, especialmente na modalidade guardar e, em tal contexto, presente a situação de flagrante, prescindível era o mandado de busca e apreensão. O crime de tráfico de droga, sendo crime permanente, enseja prolongamento no tempo da flagrância delitiva, enquanto durar a permanência, consoante se aquilata do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de sorte que apto a ensejar ação dos policiais e entrada no recinto onde o ilícito esteja sendo praticado, independentemente da expedição de mandado judicial.

Nesse sentido:

“A Constituição não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art. 5º, XI), ocasião em que se poderá efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica” (Código de Processo Penal Interpretado, JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 10ª ed., Atlas, 2003, p. 625).

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/11, documentos de fls. 12/19, laudo pericial de fls. 38/40 e pelo conjunto probatório. A autoria pelo conjunto probatório.

Caio Henrique Do Bonfim Garcia, réu, perante a autoridade policial (fl. 37), negou os fatos. Em juízo, permaneceu em silêncio. Consignou que, atualmente, está preso por ter sido apreendido como uma única porção de crack.

Carlos Eduardo Pincerati, testemunha de acusação, investigador de polícia, durante a instrução, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 59), afirmou que havia recebido denúncias anônimas e denúncias pelo canal 181, de que o Caio e sua amásia, na época, a Vitória, estavam utilizando o imóvel em que moravam, para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Foram feitas campanas, verificaram a existência de movimento anormal, que indicava possível existência de tráfico no local. Os fatos foram noticiados à autoridade policial da época, que representou ao juízo, pedido de busca e apreensão na residência. A diligência foi autorizada, e, na data dos fatos, dirigiu-se no local. Ele não foi encontrado na casa, providenciou a presença de duas testemunhas, vizinhas da casa e foi necessário o arrombamento do cadeado que trancava o portão e a porta da cozinha. O declarante foi em um dos quartos, e, em cima de uma sapateira, em local bem visível, encontrou cerca de 32 ou 37 pedras de crack, embaladas para comércio, uma porção de maconha e dinheiro trocado em miúdo, não se recorda da quantia exata, por volta de R\$ 60,00. Estava tudo em cima da sapateira. Também apreenderam dois celulares. No outro quarto, Hélio localizou R\$ 200,00 ou R\$ 300,00, objetos, tais como relógios, que apreenderam para verificar a procedência e também duas bobinas de plástico, mesmo plástico que utilizaram para embalar as porções de droga. Também apreenderam dois documentos de veículos. O material foi apresentado na delegacia. Caio não foi encontrado, tinha informação de que ele tinha ido para a cidade de Assis/SP com a amásia dele. Em seguida, o delegado instaurou inquérito para apuração dos fatos. O acusado já tinha sido preso anteriormente por tráfico de entorpecentes. Também foi apreendido pelo tráfico quando era adolescente. Inclusive, quando ele foi ouvido quanto aos fatos, encontrava-se preso em Assis, pela prática de tráfico de entorpecentes. Confirmou que era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, enquanto o declarante verificou um quarto, o outro investigador verificou outro cômodo. A polícia militar acompanhou a diligência. Não se recorda se houve registro de fotos, mas acredita que tenha tirado foto do local em que encontrado as substâncias entorpecentes. As testemunhas estavam no interior da residência e as drogas apreendidas foram apresentadas, assim que localizadas. Confirmou que acompanharam a diligência. Viram a abertura da porta e o momento em que localizaram os entorpecentes, dentro da residência. O acusado não foi localizado. Não apresentou à intimação. Foi ouvido, posteriormente, quando já se encontrava preso em Assis pela prática de tráfico de entorpecentes. As testemunhas constam no auto de busca. Era uma senhora e senhor, vizinhos de Caio. Geralmente fotografa o local, se fotografou, passou ao escrivão.

Hélio Alves da Silva, testemunha de acusação, investigador de polícia, em juízo, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 43), declarou que foram à residência de Caio, para cumprirem mandado de busca e apreensão. Foi ao local com Carlos Eduardo Pincerati e o delegado de

polícia. A casa estava trancada, não tinha ninguém. Solicitaram acompanhamento da busca por um vizinho. Tiveram que estourar o cadeado para acessar a residência. No local, encontraram uma grande porção de drogas e quantia em dinheiro. Foi tudo apreendido. O acusado não foi encontrado no local. Participou das investigações preliminares, que culminaram na expedição de mandado de busca. Confirmou que, nas diligências, apuraram a movimentação de tráfico no local, já tinham recebido muitas denúncias. O local era indicado como moradia dele. Ele não estava no local no dia da apreensão. Na busca e apreensão, um vizinho acompanhou a diligência. O delegado também acompanhou. O vizinho acompanhou toda diligência. Os policiais adentraram primeiro, armados, não encontraram ninguém. Viram a droga na cozinha. A testemunha acompanhou a apreensão. A substância entorpecente foi encontrada em um prato, em cima de uma cômoda. Explicou que tiveram acesso à casa, pela porta do fundo, que a casa tinha cozinha, e, contido à cozinha, um outro cômodo, tinha um pequeno depósito e outro cômodo, acredita que era um quarto. A droga estava visível. Tiraram fotos do local. Não providenciou as fotos. As testemunhas viram a droga apreendida. Foi informado que tratava-se de cocaína, crack, maconha. Como a testemunha não tem conhecimento técnico, explicaram do que se tratava.

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor.

Reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino. Assim, verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Destarte, para a configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a "traditio" para consumação do delito (TJSP, Apelação Criminal 1506353-79.2020.8.26.0228, Des. Klaus Marquelli Arroyo, j. 16/11/2020).

No caso dos autos, a forma de acondicionamento e a quantidade de droga apreendida permitem concluir a efetiva ocorrência do tráfico.

Não se descure, por fim, no aspecto, que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito o ônus probatório, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, na hipótese,

predito ônus probandi - pela defesa - não foi satisfeito (CPP, art. 156).

Nesse sentido:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C O ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO - LOCAL PONTO DE VENDA DE DROGAS - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BEM COMO CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO, POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O RECORRENTE EM ATITUDE TÍPICA DE VENDA DE ENTORPECENTES, NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO LOCAL DO CRIME - DESCABIMENTO - CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA TRAFICANTE OCASIONAL - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO FATORES QUE NÃO SE COADUNAM COM AQUELE QUE PRÁTICA O CRIME PELA PRIMEIRA VEZ - RÉU PRESO, APÓS SER SOLTO POR ESTE PROCESSO, POR TRÁFICO. PENAS E REGIME BEM DOSADOS - RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 0090612-04.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Nunca é demais lembrar que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não sendo possível desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal".
(TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u).

Passo à dosimetria da pena.

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, quanto ao tráfico de drogas, observo que a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado é tecnicamente primário. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. Há diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e crack), sendo o crack de elevado poder destrutivo e a cocaína em quantidade capaz de causar nefasto abalo na comunidade local, sendo necessária a elevação da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes. Descabe falar em reincidência, pois os fatos apontados pelo Ministério Público (fl. 208) foram praticados em 25/07/2019, data posterior aos fatos aqui apurados, ocorridos em 31/05/2019, conforme se verifica na certidão de fl. 176, referente aos autos sob nº 1501951-15.2019.8.26.0047 e fl. 03. Nesse sentido, permanece a reprimenda em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, no mínimo legal,

fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na derradeira fase da dosimetria, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois, apesar do acusado ser tecnicamente primário, conforme se extrai de fl. 177 possui condenação por fato posterior ao dos autos pela prática de tráfico de drogas, o que obsta a aplicação do benefício, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas. Nesse sentido: AgRg no HC 601.592/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020. Além disso, segundo o relato dos policiais, o acusado é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes e a quantidade de droga apreendida demonstra seu envolvimento, como exposto, em atividades criminosas, a corroborar a habitualidade da mercancia ilícita. Ausentes causas de aumento, fixo, definitivamente, a reprimenda, em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR Caio Henrique Do Bonfim Garcia como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

O réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado pois a gravidade concreta dos fatos destacados desautoriza regime prisional mais brando, tudo embasado nos princípios da individualização e da suficiência (cf. artigo 59, III, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

Ante o montante da pena aplicada, incabível a substituição da pena por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da execução da pena privativa de liberdade (art. 77, caput, do Código Penal).

Ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve recorrer em liberdade em relação a esse processo (art. 387, § 1º, do CPP), eis que assim respondeu ao logo do devido processo legal.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA